

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2023年2月开始，被告人陈某与上家“某某”共谋，欲通过网络使用话术引流被害人骗取钱款，后陈某通过聊天软件使用他人照片伪装自己与多名被害人聊天，骗取被害人信任，准备进一步骗取钱款。其间，上家“某某”让被告人陈某找人背设备发射信号或者向他人收购电话卡供其使用。2023年6月，被告人陈某以每张人民币600元价格向朱某某（另案处理）收购其名下的三张移动手机卡并提供给上家“某某”引流使用。2023年6月19日，被害人叶某某接到电话，对方冒充银行工作人员对其实施诈骗，最终导致叶某某被骗人民币214999元。

2023年7月11日，被告人陈某在某路x×号××楼××室被民警抓获，并扣押手机二部随案移送。被告人陈某到案后如实供述上述犯罪事实。

另查明，陈某向上家提供案涉三张手机卡，上家承诺支付其报酬人民币2300元，但未实际支付。

【案件焦点】

被告人陈某作为诈骗犯罪的从犯，未直接参与实施诈骗被害人，且尚未实际获得违法所得，对被害人的经济损失应如何承担退赔责任。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市海沧区人民法院经审理认为：被告人陈某以非法占有为目的，伙同他人通过电信网络骗取他人钱款，诈骗数额为人民币214999元，其行为已构成诈骗罪，属数额巨大。本案系共同犯罪。被告人陈某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈某曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，可酌情从重处罚。被告人陈某认罪认罚，依法可以从宽处理。因被告人陈某系从犯，且未直接参与实施诈骗被害人叶某某，对被害人叶某某经济损失214999元可以其预期违法所

得人民币2300元为限承担退赔责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元；

二、责令被告人陈某退赔被害人叶某某经济损失人民币2300元；

三、随案移送的手机两部，均依法予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的主要争议焦点在于，被告人陈某作为诈骗犯罪的从犯，未直接参与实施诈骗被害人，且尚未实际获得违法所得，对被害人的经济损失应如何承担退赔责任？是否应对被害人的所有经济损失承担共同退赔责任？本案涉及电信网络诈骗共同犯罪案件中如何划分各被告人退赔责任问题，这是实践中的一个难点问题。

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。但该规定没有明确共同犯罪中如何划分各被告人的退赔责任。在司法实践中，“部分行为整体责任”的连带退赔责任观点占主流，即同案犯应对被害人损失共同承担退赔责任。但这种做法在打击网络犯罪时会产生诸多问题。例如，电信网络诈骗犯罪，呈现犯罪分子人数众多、内部分工细致、被害人人数众多、犯罪金额巨大等特点。不同犯罪分子参与的程度、所起的作用差别巨大，如果不加以区别地责令同案犯承担连带退赔责任，会出现在共同犯罪中起辅助作用的从犯共同承担巨额退赔责任的现象，显失公平。

责令退赔是法院责令犯罪分子赔偿被害人经济损失的制度，虽非刑罚，但也是对犯罪分子经济上的一种强制，也应符合罪责刑相适应原则和公平原则，应根据犯罪主体在共同犯罪中的作用、地位予以差别认定。实践中，对于主犯

的退赔责任没有太大争议，而对从犯的退赔责任划分是实践中的难点。以电信网络诈骗为例，整个犯罪链条，从犯所起作用多种多样。有的是直接实施某起诈骗犯罪行为从犯；有的是提供支付结算帮助的从犯；有的则是提供通讯技术帮助的从犯；等等。

对于电信诈骗犯罪的从犯应如何划分退赔责任的问题，笔者认为，应根据具体案件情况，区分从犯所起的作用来划分从犯的退赔责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，从犯区分为起“次要作用”或“辅助作用”。两种作用存在程度上的不同。比如，对直接实施具体诈骗行为的从犯，应认定为起次要作用的从犯，这类从犯应当对其行为给被害人造成的全部经济损失承担退赔责任；对提供银行卡等直接结算工具或提供通讯技术帮助的从犯，应认定为起辅助作用的从犯，可以违法所得为限承担退赔责任。

本案中，被告人陈某向他人收购移动手机卡并提供给上家引流使用，上家使用该手机卡向被害人拨打电话实施诈骗行为，上家承诺支付被告人陈某报酬人民币2300元，但未实际支付。笔者认为，被告人并未直接实施诈骗被害人的行为，根据被告人参与程度，认定被告人陈某系在共同犯罪中起辅助作用的从犯。如果责令其对被害人的所有经济损失承担共同退赔责任，显然违反罪责刑相适应原则和公平原则，故应以被告人的违法所得为限承担退赔责任。但本案特殊之处在于，被告人尚未实际获得违法所得，是否能以此免除退赔责任？对此，笔者认为，被告人虽未实际获得违法所得，但仍应当承担退赔责任，可以其预期违法所得为限承担退赔责任。该裁判方法一定程度上解决实务中起辅助作用

的从犯在尚未实际获得违法所得情况下如何承担退赔责任的问题，具有参 考意义。

编写人：福建省厦门市海沧区人民法院 张晨玮 尹志泉

提供车辆构成醉酒型危险驾驶罪共犯的认定

—— 国某某危险驾驶案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市博山区人民法院(2024)鲁0304刑初108号刑事判决书

2. 案由：危险驾驶罪

【基本案情】

被告人国某某系鲁××××x号小型轿车的所有人。2023年8月3日下午，刘某某(已另案处理)驾驶该车载国某某前往某烧烤店院内聚餐；其间，被告人国某某与刘某某、谷某某、翟某某均共同大量饮酒。21时50分许，国某某通过微信联系孙某某前往用餐处代其驾车，但孙某某未前往。21时52分45秒左右时，四人离席后，刘某某驾车驶出大院，国某某随即上车。在大院门口，因车辆右前胎胎压不足，翟某某下车用气泵给轮胎充气。随后，刘某某继续驾驶车辆沿人民路行驶。22时02分，车辆行驶至某小区门口附近时，将步行的任某某、孟某撞倒，致使任某某当场死亡，造成道路交通事故。民警当晚带刘某某抽血并送鉴定，经鉴定，在刘某某血液检材中检出乙醇成分，乙醇含量为130.26毫克/100毫升，属于醉酒后驾驶机动车。经认定，刘某某负事故的全部责任。

【案件焦点】

明知他人醉驾仍提供车辆是否构成危险驾驶罪的共犯。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市博山区人民法院经审理认为：被告人国某某作为机动车所有人和管理人，违反道路交通安全法规，明知他人醉酒，仍为他人提供其管理的机动车并同乘，未采取实质性劝阻措施，放任他人醉酒驾驶机动车在道路上行驶，发生交通事故并负事故的全部责任，其与他人危险驾驶罪范围内成立共同犯罪。公诉机关指控被告人国某某犯危险驾驶罪成立。被告人国某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有视为自首情节，庭审中自愿认罪认罚，已按照赔偿协议赔偿被害人近亲属经济损失并取得了谅解，符合缓刑适用条件，依法对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。关于被告人国某某的辩护人辩称国某某不构成犯罪的意见，法院综合评判如下：（1）被告人确与刘某某等人一起饮酒，之后明知刘某某饮酒后仍提供车辆由其驾驶并同乘，对此有监控视频及证人证言、被告人与同案人员供述互相印证，足以证实，辩护人辩称无证据直接证明该事实与查明的事实不符，本院不予采纳。（2）在案证据显示，被告人国某某案发前虽有口头劝阻及提前联系代驾的举动，但最终未转化为实质性有效劝阻措施，未尽到车辆所有人和管理人应尽的义务，放任他人醉酒驾驶，进而发生交通事故，双方存在危险驾驶的共同故意，发生事故亦未超出其应当预见的范畴。

依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款，第七十三条第一款及第三款，第五十二条、第五十三条、第六十一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决被告人国某某犯危险驾驶罪，判处：

拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

危险驾驶罪的主体主要是机动车驾驶人员，但从司法实践看，机动车驾驶人员以外的主体可以与机动车驾驶人员一起共同实施危险驾驶犯罪，比较典型的为机动车所有人、管理人明知他人醉酒驾驶仍为其提供机动车的情形。如何准确认定提供车辆而构成醉驾型危险驾驶罪的共同犯罪问题，成为实务中亟须厘清的难题。

一、出借车辆存在构成醉驾型危险驾驶罪共同犯罪的适用空间

根据我国刑法理论，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。理论界大部分学者认同，在醉驾型危险驾驶罪中，只要行为人对于醉驾行为本身具有故意，就应当构成故意犯罪，而不能根据其对于危险结果具有过失而认定为过失犯罪。^①笔者同意该观点，据此认为共同犯罪理论应当适用于醉驾型危险驾驶罪共犯的认定。关于醉驾型危险驾驶罪共犯主体范围的认定，实践中存在一定争议。有观点认为，醉驾型危险驾驶罪的共犯应仅限于对车辆负有安全管理和安全驾驶义务且教唆并引发他人醉驾犯意，并提供车辆的人员。持此观点者认为，单纯的出借车辆行为并不会侵害相关法益，危险驾驶与否仍由驾驶人自身意志所决定，只有实施了教唆行为引发驾驶人醉驾犯意的才具有刑事可罚性。除前述人员外的其他同乘、同饮人员，既不具有安全管理等法定义务和能力，也不具有左右驾驶人醉驾与否的原因力，即便其具有劝酒、教唆、胁迫、命令等行为，也不应认定为危险驾驶罪的共犯。另一种观点认为，不对醉驾型危险驾驶罪共犯的主体范围作限制认定，按照一般共同犯罪理论作出认定即可。笔者同意后一种观点，认为醉驾型危险驾驶罪的共犯主体应为一般主体。根据刑法共同犯罪理论，教唆他人犯罪或者明知他人要实施犯罪而给予帮助的，教唆者和帮助者都与实施犯罪者构成共同犯罪。由此可推导得出，在危险驾驶罪的共犯认定中，教唆他人危险驾驶者或者明知他人危险驾驶仍给予帮助的，教唆者和帮助者都与危险驾驶人存在共同犯罪的可能性。据此，醉驾型危险驾驶罪的

^①陈兴良：《风险刑法理论的法教义学批判》，载《中外法学》2014年第1期。

共犯主体并不局限于机动车所有人、管理人等对机动车负有安全管理和安全驾驶义务的人员这些特定主体，应确定为一般主体。如若同乘、同饮人员实施了劝酒、教唆、胁迫、命令等行为，亦可能会被认定为危险驾驶罪的共犯。据此，出借车辆人员存在构成醉驾型危险驾驶罪共同犯罪的适用空间。是否构成共同犯罪，并不取决于驾驶人醉驾的决定性原因力。《中华人民共和国刑法》第十八条第四款规定，醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。即我国刑法认为醉酒的人是负有辨认和控制能力的。醉驾与否是驾驶人自由意志决定的，但该认定不能否定教唆和帮助行为被认定为犯罪行为。因为所有犯罪都是实施犯罪者自由意志选择的结果，在其他犯罪中犯罪原因力不影响教唆者、帮助者共同犯罪认定的情况下，醉驾型危险驾驶罪共犯的认定也无须过多考量驾驶人醉驾的原因力问题。

二、因出借车辆而构成醉驾型危险驾驶罪共犯的，需以主观明知为前提

车辆所有人、管理人因出借车辆而构成醉驾型危险驾驶共同犯罪的，需存在共同犯罪的故意，即各行为人通过犯意联络，明知自己与他人共同实施危险驾驶犯罪会造成某种危害结果，并且希望或者放任这种危害结果发生的心理态度。在危险驾驶共同犯罪中存在共同直接故意、共同间接故意及直接故意与间接故意的组合三种具体罪过形态，个案中需具体分析后准确认定。对车辆所有人、管理人而言，明知的范围不仅是他人已醉酒，还包括明知他人实施危险驾驶行为。实践中，单纯地明知他人醉酒并不必然能够推导得出出借人明知他人醉驾而出借的结论。实务中确存在醉酒者委托其他未饮酒者驾驶或本人酒醒后才驾驶的情形，具

体仍需结合行为人的供述、场景的还原综合认定，只有确有 证据证实出借车辆者明知对方醉酒且自驾，才能构成醉驾型危险驾驶罪共犯主 观上的明知。本案中，被告人在与驾驶人共饮后，仍提供车辆供他人驾驶，自 己还同乘离开，主观上的明知是清晰且无争议的。

三、因出借车辆而构成醉驾型危险驾驶罪共犯的，其刑事责任按危险驾驶 行为人的入罪构成要件予以评判

行为是否成立犯罪，以行为是否符合刑法分则的构成要件规定、是否具备

犯罪成立条件为准。①实务中，对出借车辆的机动车所有人、管理人予以刑事评价通常以危险驾驶行为人血液中酒精含量的检测结果作为认定依据。如若无其他特殊情节，综合危险驾驶行为人驾驶的动机和目的，机动车类型、道路情况、行驶情况及认罪悔罪表现等因素综合认定即可。出借车辆的行为系对醉驾的帮助行为，出借行为人构成醉驾型危险驾驶罪的帮助犯，根据双方在共同犯罪中的地位和作用，前述帮助犯一般可认定为从犯，做到区别对待。

如若危险驾驶行为人醉驾同时构成交通肇事罪、过失以危险方法危害公共安全罪、以危险方法危害公共安全罪等其他犯罪的，对危险驾驶行为人依照处罚较重的规定定罪，依法从严追究刑事责任，对此法律有明确规定，并无争议。但在危险驾驶行为人构成其他犯罪的情况下，如何对出借车辆的机动车所有人、管理人的入罪标准、定罪情节予以恰当评价存在一定争议。以本案为例，在危险驾驶行为人因醉驾发生交通事故构成交通肇事罪的情况下，是否将发生交通事故作为出借车辆共犯的入罪标准、定罪情节予以评价，存在两种不同观点。一种观点认为，驾车造成交通事故一般而言是过失行为，过失行为不成立共同犯罪，因此，一般不应将发生交通事故作为出借车辆者的入罪标准、定罪情节。持此观点者认为，在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》（以下简称醉驾意见）实施后，如提供车辆者无法预见事故的发生，危险驾驶行为人醉驾时血液酒精含量不满150毫克/100毫升的，如不具有醉驾意见第十条规定的其他情形的，可对提供车辆者不作犯罪处理。另一种观点认为，此种情形下，出借车辆者与危险驾驶行为人在危险驾驶罪范围内成立共犯，出借车辆者主观上应当能够预见驾驶行为人醉酒驾驶可能会发生交通事故的后果，放任该后果的发生，实际发生交通事故后果并未超出行为人预期，应将发生交通事故纳入出借车辆者定罪、量刑情节在危险驾驶罪中予以评价。笔者同意第二种观点，根据理论通说，醉驾型危险驾驶罪属于抽象危险犯，即立法者对“只需一般的社会经验即可认定具有危险”的行为的类型化。学界通常认为，醉驾型危险驾驶行为的抽

①周光权：《论刑事一体化视角的危险驾驶罪》，载《政治与法律》2022年第1期。

象危险是对公共交通安全造成侵害的危险，或者说使公共交通安全处于危险的状态。站在一个受过正常社会教育的一般人视角，其在提供车辆供醉酒者驾驶时，应当会意识到即使凌晨在目测无人的道路上醉酒驾驶，内心也会有“隐约的担忧”，不能排除道路上突然窜出来行人或者车辆，进而发生事故的可能，因而应当确定提供车辆者对发生事故具有预见可能性。但致人伤亡等其他严重后果则可能超出车辆出借者的预期，当事人之间对危害后果不存在共同罪过，不符合共同犯罪原理。另外，应正确把握醉驾意见第十条和第十二条的理解与适用。根据体系解释可以确定，醉驾意见第十条除量刑时起从重处罚作用外，还结合第十二条规定起反向排除作用，将那些反映醉驾情节严重的情形排除在认定为情节显著轻微之外，处理上体现从严立案。在危险驾驶行为人为醉驾发生严重道路交通事故，构成其他犯罪的情况下，如还对提供车辆者认定为情节显著轻微，明显超出人民群众朴素的法律认知，有违实质性公平正义。

四、出借车辆者阻却犯罪需采取实质性举措阻止驾驶人醉驾发生

犯罪的实行行为是指刑法分则中具体犯罪构成客观方面的行为。刑法理论认为，在共同犯罪领域，实行行为是实行犯成立的基本要件，是实行犯与教唆犯和帮助犯相区别的重要标志。“没有行为则没有犯罪”，实行行为的存在，是实行犯得以成立并被追究刑事责任的客观要件和前提^①。在醉驾型危险驾驶共同犯罪中，提供车辆者的犯罪形态以驾驶行为人的犯罪形态为标准把握。作为危险驾驶罪构成要件意义上的“醉驾”，即醉酒后在道路上驾驶机动车的行为，要求机动车在道路上处于运动的状态。《中华人民共和国刑法》第二十三条规定的犯罪既遂标准是“得逞”。

这种“得逞”是站在立法者、社会立场上对犯罪行为所进行的评价。换言之，当犯罪行为对刑法规范所保护的特定利益即刑法法益实施了侵犯时，就是犯罪“得逞”。这一法定既遂标准适用于包括危险驾驶罪在内的所有的犯罪形态。据此可以这样理解，行为人一旦着手实施“醉驾”行为，其行为即被立法者认为对公共交通安全造成了抽象危险，无须考虑其持续的时间长短。时间长短仅仅是刑罚裁量的因素。换言之，“醉驾”行为

①叶良芳：《实行犯研究》，法律出版社2001年版，第33页。

与“抽象危险”的出现具有同步性，须臾不可分离，二者之关系犹如“影”与“形”之关系。^①现实中，醉驾人员实施的发动机动车引擎、上路前的热车准备之类的行为不应被理解为“醉驾”行为，可认定为“危险驾驶罪”的预备行为。据此，醉驾型危险驾驶罪并不存在犯罪未遂形态的余地，行为人一旦醉酒驾驶引发了抽象危险，危险驾驶罪即告既遂，此时不再存在行为人消除危险的中止情况。对于车辆提供者而言，阻却违法的关键在于事前采取实质性措施阻止驾驶人着手实施犯罪，如若仅采取口头劝阻等措施，未能采取实质性举措阻止驾驶人醉驾的，不阻却本人犯罪（共犯）的成立。

编写人：山东省淄博市博山区人民法院 卜凡国

虚构平台、夸大前景以引人“老带新”投资属于传销活动

—— 李某、谢某等组织、领导传销活动案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省永州市中级人民法院(2023)湘11刑终750号刑事裁定书

2. 案由：组织、领导传销活动罪

【基本案情】

2020年8月至2022年5月，生物科技公司以推行小白鼠养殖获取分红为借口，在小白鼠养殖未实现营利情况下，在某区块链平台（基于区块链的去中心化平台）发行A币，以人民币兑换C币购买A币、在商城购买商品等形式变相

^①陆诗忠：《论“危险驾驶罪”司法适用中的几个疑难问题》，载《甘肃政法学院学报》2018年第2期。

收取会员门槛费，大肆宣传，以发展下级会员给予上线及团队长奖励，吸引资金拉升A币值，获得释放并交易A币获利。该组织以李某为主要发起人、策划人、操纵人，以谢某、王某、廖某、许某、黄某等人为传销组织的管理、协调、宣传、培训人员，聘请技术人员和系统运维人员，为该组织持续发展会员，骗取更多钱财实现稳定运行。

2020年11月，李某通过考察做小白鼠养殖项目，并决定把小白鼠养殖与H币项目结合起来，以小白鼠养殖这一实体项目的巨大利润为诱饵来包装、宣传推广H币。2021年2月左右，李某、王某、黄某、黄某1、李某1等人在某租赁办公场所将生物科技公司搬到东莞市办公。为了包装生物科技公司推广的小白鼠养殖项目，李某及相关推广人员为生物科技公司和小白鼠养殖项目拍摄宣传片，欺骗群众投资小白鼠养殖项目，对外宣称生物科技公司是与“A国卫生研究院”进行战略合作的，“A国卫生研究院”负责高价回收与生物科技公司合作的小白鼠养殖户的小白鼠血清。2021年7月左右，因为H币项目出现问题，李某决定另外发行一种新的虚拟币，将H币项目的会员数据进行转移。

2021年8月22日，生物科技公司在某区块链平台发行A币，发行数量300万个，发行成功后，李某安排王某销毁其中的268万个，余下32万个，留出1.3万个A币用于公司运营以及市值管理，除平移的A币及公司留下的1.3万个A币外，余下的20多万个A币属于生物科技公司所有，并放入李某、王某、黄某与下面的团队长共建的监管钱包里共同监管。公司预留A币1.3万个交由王某管理，用于给会员发放发展下线奖励、给团队长发放团队发展会员奖励等方面开支。生物科技公司发行A币之后，开始在线上以公司代会员养殖小白鼠可获得高额血清分红的模式推广A币，但实际会员购买A币营利并不是完全与公司代养小白鼠分红相关联，而是通过不断地扩大授课、培训等多种模式宣传推广，依靠不断发展下线、拉会员来拉升A币价值及其释放比例，再将A币变现营利。

生物科技公司按时间先后推行了股东会员、蓝钻会员、白金会员、鼠宝宝会员等四种会员模式。要求加入人员先在平台上花几千元到3万元不等的人民

币投资A币并质押到监管钱包才能成为相应的会员，享受小白鼠血清分红，变相收取门槛费，成为公司会员后通过感恩码发展下线得到奖励。

自生物科技公司2021年8月22日在某区块链平台发行A币上线运营至2022年5月29日止，经鉴定：(1)通过对数据库进行分析，发现平台具备发展下线会员，并按照下线人员投资金额进行获利的功能。(2)对数据库中人员信息进行统计，以某区块链平台钱包登录过系统的总数为442490个，通过实名认证的用户共计191035人。其中股东会员264个；蓝钻会员11972个；白金会员42384个；鼠宝宝会员1671个。用户之间存在上下层关系，层级最多的用户共计30层。(3)对数据库中转入“监管钱包”和“资金池”的资金进行统计，转入“监管钱包”总计：261486.6A币；转入“资金池”总计：101569.6A币。“血清收益”中“已打款”总计：585897元(分红收益：538193元；团队收益：47704元)。用户每推荐激活两名蓝钻会员，会释放0.1A币到该用户钱包，释放记录总计4714条，总计释放A币数量：511.6个。(4)商城管理系统中商城会员总数为：442558个。已完成订单：7873条，其中已完成订单金额总计：8688205.5元。(5)商城管理系统中具有团队奖励资格的有九人。商城奖励中直推释放记录2280条，总计释放A币数量：140.685379个。团队释放记录19条，总计释放A币数量：0.384923个。经某会计师事务所鉴定：某生物科技公司获取的资金流入为92271934.51元(含C币13027021.44个，按该时间段美元兑人民币最低换算比率2022年3月1日1C币等于6.3014元比率折合人民币82088472.90元)。结合某司法鉴定所会员鉴定数量(蓝钻会员为11972个、白金会员为42384个、鼠宝宝会员1671个)，测算会员缴纳门槛费位于332559050.00元至452279050.00元区间内。

【案件焦点】

1. 李某等六名被告人的行为是否构成组织、领导传销活动罪；2. 鉴定意见能否作为定案依据；3. 关于六名被告人主犯、从犯的认定；4. 被告人非法所得的认定。

【法院裁判要旨】

湖南省蓝山县人民法院经审理认为：

一、本案各被告人是否构成组织、领导传销活动罪

经查，被告人李某伙同谢某、王某、廖某、许某、黄某等人以经营活动为名，要求加入者以缴纳相应等级数额的费用，换取一定价值的数字货币获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱加入者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人黄某的辩护人提出被告人黄某不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，本院不予采纳。

二、关于某司法鉴定所、某会计师事务所出具的鉴定意见能否作为定案依据

经查，某县公安局就全案被告人涉案相关事项委托鉴定机构进行鉴定，其中，某司法鉴定所根据委托事项对手机、电脑提取恢复和固定的电子数据分析得出的电子数据鉴定意见，并在电子数据的基础上得出了司法鉴定意见。某会计师事务所根据委托事项对本案涉案银行、微信、支付宝、易宝付账户及账户交易流水、交易记录，涉案金额，获利进行会计鉴定，上述鉴定机构具有鉴定资质、鉴定程序合法，内容客观真实、具有法律效力。被告人及辩护人辩称本案鉴定意见存在“一人多号”等情形，不能直接以此认定各被告人实际发展的传销活动下线人数和层级，经查，根据被告人的供述和多位证人的证言，本案确有部分传销活动参与者借名注册多个会员账号使用的情况，但参与者已通过借名注册的方式形成了事实上的多层级，并且达到了个人获取更多直推奖励及A币释放比例等收益的目的，为传销活动进一步发展起到了推进作用，此现象也是本案传销活动组织、领导者所设置的规则为吸引更多资金流入所导致，不能以此从轻、减轻各被告人的处罚，对于被告人及辩护人的该辩护意见本院不予采纳。

三、关于被告人李某、谢某、王某、廖某、许某、黄某主从犯的认定

经查，被告人李某系传销组织的发起人、策划人、操纵人，担任公司的董

